

1501567-35.2020.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... da confissão apenas para o crime de tráfico, e também com a redução da pena deste, mas em percentual menor, com o aumento da pena do desacato por serem duas vítimas e absorver a resistência, discordando da substituição pela pena restritiva de direitos para os dois delitos, fixando-se regime prisional semiaberto ao tráfico e o aberto ao delito para o desacato, sem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501567-35.2020.8.26.0537 - Controle nº 2020/001295

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2218382/2020 - 02º D.P. DIADEMA, 13379649 - 02º D.P. DIADEMA, 1496/20/123 - 02º D.P. DIADEMA, 2218382 - 02º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cleiton Alves Feitosa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

CLEITON ALVES FEITOSA, qualificado às fls. 14 e 29/30, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e no artigo 331, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, combinados na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, porque no dia 03 de setembro de 2020, por volta das 15h10, no cruzamento da Passagem do Progresso com a viela Tião Carreiro, Vila Nogueira, nesta cidade de Diadema trazia com ele e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 27 embalagens plásticas contendo 21,83g da droga cocaína, 32 embalagens plásticas contendo 7,81g da mesma droga, na forma de crack e 26 embalagens plásticas contendo 48,29g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição

de fls. 10/11 e laudo de constatação provisória de fls. 21/27, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de local e tempo acima indicadas, CLEITON ALVES FEITOSA, desacatou os policiais civis Marcus Vinicius Faria Rodrigues Rotondo e Marcos Aurélio Pires Nabor, funcionários públicos e que estavam no exercício de suas atribuições funcionais.

Concedida a liberdade provisória ao réu (fls.57/59), e não sendo hipótese de aplicação da ANPP, até por estar preso por outro processo, foi ele citado (fl. 97), nomeado Defensor Público, quem apresentou defesa inicial às fls.99/101. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 29/09/2021 (fl.77).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram as testemunhas comuns e interrogado o réu ao final. Encerrada a instrução sem requerimento de diligências, seguiu-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o d. representante do Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação das penas base acima do mínimo diante da quantidade e nocividade da droga cocaína e por terem sido dois xingamentos contra dois policiais além da resistência, concordando com atenuante da confissão apenas para o crime de tráfico, e também com a redução da pena deste, mas em percentual menor, com o aumento da pena do desacato por serem duas vítimas e absorver a resistência, discordando da substituição pela pena restritiva de direitos para os dois delitos, fixando-se regime prisional semiaberto ao tráfico e o aberto ao delito para o desacato, sem possibilidade de recurso em liberdade.

Já o d. Defensor Público reiterou o pedido de absolvição ante a fragilidade probatória, especialmente para o crime de desacato entendendo tenha se tratado de mero descontrole emocional. Subsidiariamente, requereu que as penas-bases fossem fixadas no mínimo legal, com a atenuante da confissão, com o redutor da pena do tráfico e não aumento da do desacato, com a substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime aberto e possibilidade de recurso em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fls.10/11, nos laudos de constatação e no definitivo (fls.21/23 e 119/121, respectivamente), ambos positivos para as drogas maconha e cocaína.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais civis (fls.12 e 13), avistaram o réu num ponto de venda de drogas já conhecido e resolveram aborda-lo. Com ele apreenderam uma sacola que estava em sua parte íntima, na frente, e continha as drogas descritas, tendo ele dito: "perdi". Ao ser algemado, ele se exaltou, xingou a equipe de "lixo e verme", resistindo à prisão, se debatendo, tendo que usar força moderada para conte-lo.

Sob o crivo do contraditório o policial Marcus Vinicius Rotondo reiterou que o local é um ponto de venda de drogas e visualizaram o réu ali, parado. Ele foi abordado. Nas partes íntimas dele tinha uma sacola com 85 tipos de drogas, dos três tipos (cocaína, crack e maconha), e dez reais da venda que ele disse que havia feito. O réu falou: "perdi". Ele não quis ser algemado, ficou exaltado, e os xingou

de vermes e lixo. Ficaram constrangidos, é deselegante essa tratativa para com eles. O acusado também não queria ser algemado, e houve necessidade do uso de força e da algema para conte-lo. No DP ele confessou que estava há três dias comercializando as drogas, que estava em situação de morador de rua e queria alugar uma casa para morar. Ele disse que também fazia uso de cocaína. Reconhece o réu e foi a primeira vez que o viu no local.

Neste sentido foi o depoimento judicial do policial Marcos Aurélio confirmou que diligenciavam no local, ponto de venda de drogas. Avistaram o réu e o abordaram. Ele já falou: "perdeu". Ele tirou da parte íntima dele um saco contendo as drogas e uma pequena quantia em dinheiro. Ao chegarem na viatura ele se rebelou, começou a xinga-los e tentou impedir que o levassem à delegacia de polícia. Ele os xingou de vermes, e de sua raça negra. Ele xingava e os desqualificava no plural também. Sentiu-se ofendido, porque está protegendo a sociedade de pessoas que estão traficando. Reconhece o réu.

O réu, em solo policial (fl.14) confessou que estava vendendo as drogas e que o dinheiro apreendido era da venda delas. Que é usuário de cocaína, e estava morando na rua, pretendendo usar o dinheiro que ganharia no tráfico para pagar um aluguel.

Em juízo o acusado alegou que realmente estava no local, em situação de rua, precisando de dinheiro para sair dessa situação. Foi abordado pelos policiais, mas não chamou ninguém de negro. Não quis deitar no chão, mas que podia ser algemado, e nisso levou um soco. Não chamou ninguém de lixo nem de vermes. Não resistiu à prisão, só não quis deitar no chão. Estava sob o efeito de bebida e cocaína. Teve liberdade assistida por crime análogo a assalto quando adolescente. Posteriormente aos crimes em tela, voltou a assaltar, e está preso por isso.

Logo, o interrogatório com a confissão parcial do acusado quanto ao crime de tráfico, que não é prova única, pois veio corroborada pelos depoimentos dos testemunhos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária. Inclusive no que concerne ao delito de desacato, embora quanto a este o réu não seja confesso, mas ao ser questionado sobre os xingamentos, ele disse que não rotulou ninguém de negro. E ao ser questionado sobre os xingamentos que de fato constam na denúncia: vermes e lixo, também os negou, dizendo que só não obedeceu a ordem de se deitar ao chão, mas que podia ser algemado, ao que teria levado um soco, mas nada disso foi provado por si nem pela Defesa, como lhes competia o ônus dessa prova. Ademais, pouco crível que tenha sofrido violência física e que tenham mandado se deitar ao chão se não mostrou resistência desde o início, pelo contrário, falou: "perdi", se entregando, de modo que desnecessário o uso de algema, de força, enfim, incompatível a conduta que o acusado hoje trouxe como sendo a dos policiais, por falta de necessidade e por ser incompatível com toda a prova e conduta amigável do réu até ser levado à viatura e resistir a embarcar, passando então a xinga-los também.

Embora haja somente os relatos dos dois policiais, não há sequer indicio de suspeição ou interesse pessoal deles no deslinde do feito contra o réu. Ora: o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, HC 76.608-0).

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares ter em depósito e guardar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

No mais, não procede a tese de se tratar de mero usuário, posto que não demonstrado cabalmente como competia o ônus dessa prova à Defesa. Ademais, a condição de usuário de drogas não afasta a traficância, uma vez que é comumente sabido que dependentes químicos utilizam o tráfico de entorpecentes como meio de perpetuar o vício, de modo que as condutas coexistem, não se excluem, donde afastado o pedido de desclassificação.

Cito jurisprudência nesses termos: A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira).

Afasto tese de estado de necessidade ou de situação de pobreza do réu que se disse desempregado, morando na rua, pois os bens jurídicos são desproporcionais, por se colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade, em detrimento do interesse individual, além de se tratar de crime de perigo abstrato, e porque não há prova nos autos de miserabilidade extrema que o réu passasse a ponto de ter que violar a lei para sobreviver. A mera dificuldade financeira não autoriza ninguém a praticar delitos (nesse sentido vide: TJSP, Apelação Criminal n.º 0006727-87.2004.8.26.0081, Rel. Caio Ferraz de Camargo Lopasso, 5.ª Câmara Criminal D.J.E., j. em 29.07.2011) assim como a situação de desemprego não pode ser aceita como causa excludente de ilicitude sob pena de se legalizar a prática de crimes por todo e qualquer indivíduo que esteja desempregado e em precárias condições econômicas - o que não é aceitável.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaina), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido (fl.76), são fatores que reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

E quanto ao crime de desacato, em que pese a Defesa pretender seu afastamento, deve-se ter em mente que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, e que o Direito Penal serve para proteger interesses e direitos relevantes. Assim como os agentes públicos não podem agir com arbitrariedade sob pena de responderem penal e administrativamente, devem ser considerados vítimas quando o caso como no desses autos, que os policiais confirmaram terem ficado constrangidos com os xingamentos e que é deselegante esse tipo de tratativa para com eles, sem que isso configure tratamento privilegiado, mas sim proteção da função pública por ele exercida. E nessa toada é que o réu, ao ser detido, xingou os policiais de lixo e verme e não queria ser algemado, tendo que fazer uso de força para conte-lo e até algema-lo dada à resistência.

Ora o crime é desacatar, que significa ofender, humilhar, desprestigiar, menosprezar, agredir o funcionário, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro da função, pouco importando que o funcionário se julgue ou não ofendido, já que a ofensa é dirigida também à dignidade e ao prestígio de seu cargo ou função. Como visto, não se tratou de mera arrogância nem de mera repulsa, exaltação ou crítica, e sim de ânimo de ofensa, afronta, desprestígio e humilhação dos funcionários públicos que estavam exercendo sua função e as ofensas foram proferidas em razão

daquelas, tendo ambos se sentido desprestigiados, ofendidos. Dito isso, não se alegue mero descontrole emocional pelo uso de cocaína e álcool, pois não provado pela Defesa, como dito e não provado por esta, como já visto.

Nesse sentido vide: Crime contra a honra. Desacato a policiais militares, a expressão vagabundo denota qualidade inferior, reles, ordinário, vadio, representa humilhação, desprestígio ao policial que, no exercício de seu encargo público, garante a ordem social, superando as adversidades levadas pela baixa remuneração e precariedade de meios para o cumprimento do seu dever. As demais expressões dirigidas à mulher policial, cadela, a significar meretriz, de igual, caracteriza, sem sombra de dúvidas, no conjunto probatório, a vontade inequívoca e deliberada de ofender, tipificando o delito de desacato (RJTJERGS 190/135).

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito a não demandar aumento inicial na pena, assim como a quantidade de narcótico que não reputo excessiva, às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base mínima: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa para o tráfico; e em 07 meses de detenção pelo desacato, e não mera multa por terem sido proferidos mais de um xingamento contra mais de um policial demonstrando maior audácia e desrespeito por parte do réu, e porque houve também uma resistência física contra os policiais, como descrito e provado nos autos e aqui absorvido e considerada uma conduta única. Assim, tem-se o discreto aumento inicial da pena.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes contra nenhum dos crimes, e sim a atenuante da confissão, quanto ao crime de tráfico apenas, e tendo sido utilizado o interrogatório como meio de prova de autoria para a fundamentação do presente decreto condenatório, milita em seu favor a atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, mas não se tem como reduzir as penas aquém do mínimo legal já fixada, consoante Súmula 231 do STJ, permanecendo em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ausente atenuante pelo crime de desacato, pois o réu não o confessou, de modo que inalterada essa pena nessa etapa (07 meses de detenção).

Em terceira fase, não concorrem causas de aumento de pena para o tráfico. Quanto ao privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, o Réu faz jus ao beneplácito legal, porquanto seja primário (fls.74/75), mas considerando a apreensão dinheiro, ainda que pouco (R\$ 10,00) proveniente de efetiva venda de drogas a usuário, disseminando e contribuindo com o vício, entendo que o redutor de 3/5 é o razoável e proporcional à maior dedicação do réu à traficância ilícita, totalizando 02 anos de reclusão e 200 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo atual tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

E no que tange ao crime de desacato, aumento a pena em 1/6 diante do disposto no art. 70 do CP, ou seja, porque uma só ação o réu praticou duas ofensas a dois policiais diferentes, os xingando no plural inclusive, além da resistência à prisão, de modo que com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade às condutas perpetradas pelo acusado, a pena irá para 08 meses e 05 dias de detenção. Sem causa de redução dessa pena.

Nos termos do art. 69 do CP, somo as reprimendas que totalizam 02 anos de reclusão, 08 meses e 05 dias de detenção e o pagamento de 200 dias-multa.

O quantum da condenação, a primariedade e a pouca quantidade das penas permitem ao réu iniciar o cumprimento das penas privativas de liberdade no regime aberto a teor do disposto nos artigos 33, do Código Penal e porque os crimes não foram praticados

com violência nem grave ameaça à pessoa.

Contudo, incabível a benesse do art. 44 do CP, não se mostrando suficiente nem eficaz à reprovação da conduta do agente, menos ainda socialmente recomendável sob pena de potencializar a sensação de insegurança e intranquilidade social, a merecer maior reprovabilidade a conduta, dado que viola mais intensamente o bem jurídico tutelado, somado ao elevado número de ocorrências de tal natureza conferindo constante desassossego à sociedade, a exigir firme repressão do Estado como forma de desestimular o crime, geralmente cometido graças ao nível de organização próprio daqueles que fazem do tráfico seu meio de vida. Não bastasse isso, artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves .

Vedo o recurso em liberdade por ter o réu descumprido as condições de sua soltura, já que em setembro de 2021 ele foi agraciado com a liberdade provisória e tornou a delinquir, em crime grave, assalto. Dito isso, e pela reiteração criminosa, faz-se necessária a prisão para garantia da ordem pública e para a devida aplicação da lei penal, já não fosse suficiente a justificativa do descumprimento das condições alternativas para sua soltura.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra CLEITON ALVES FEITOSA, qualificado às fls. 14 e 29/30, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e no artigo 331, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, combinados na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, e o faço para condená-lo à pena de 02 anos de reclusão, e 08 meses e 05 dias de detenção, em regime aberto, mais ao pagamento de 200 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Expeça-se mandado de prisão contra si.

Sendo ele assistido pela DPE, reconheço suspensa a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora.

Decreto a perda de valores apreendidos nestes autos (fl. 76), com fulcro no art. 63

da Lei 11.343/06. E determino a incineração de todos os entorpecentes.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias sob pena de extração de certidões da Sentença para a Procuradoria Geral do Estado (dívida ativa.

Oficie-se ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA